

1500331-28.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Souza Nucci ensinam que a associação para o tráfico de drogas estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Portanto, configurar-se-á o delito ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500331-28.2022.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500331-28.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2068918/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 23554594 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 1982/22/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2068918 - DEIC - TAUBATE, 1982/22/516 - DEIC - TAUBATE, 2068918/2022 - DEIC - TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LEANDRO DE SOUZA LIMA e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

LEANDRO DE SOUZA LIMA, qualificado nos autos às fls. 10, e NICOLAS HENRIQUE RODRIGUES SALGADO, qualificado nos autos às fls. 85, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, ambos do Código Penal, sob a acusação de que na tarde de 11 de março de 2022, por volta das 15h00m, na Rua Lourenço da Veiga e, ulteriormente, na Avenida Vila Velha, ambos os logradouros no Bairro Ipanema, nesta cidade e comarca, LEANDRO trazia e guardava consigo, para o fito de entregar a consumo de terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, vinte e quatro gramas e oito decigramas (24,8 g), aproximadamente, da droga cocaína, determinante de dependência física e psíquica, consoante testifica o auto de constatação acostado nos autos e conforme demonstrará laudo de exame químico toxicológico que oportunamente se entranhará.

Consta na denúncia que encontrava-se o narcótico acondicionado em sessenta e quatro (64) invólucros, parte distribuída em vinte e seis (26) unidades contendo seis gramas e um decigrama (6,1 g) da substância ilícita em sua forma compacta (pedras

de crack) e parte em trinta e oito (38) envoltórios contendo dezoito gramas e sete decigramas (18,7 g) da droga em sua forma pura e natural (pó branco de granulometria fina), repartido o estupefaciente em embalagens preparadas como porções individuais para a venda no varejo.

Versa a inicial que as drogas destinavam-se à mercancia ilícita, conforme se depreende de sua quantidade, forma de apresentação e diversidade, assim como do horário e local de sua apreensão, ocorrida inicialmente na Rua Lourenço da Veiga por ocasião de patrulhamento policial de rotina ali efetuado, oportunidade em que o réu LEANDRO, na posse de dez (10) porções de crack e oito (8) do mesmo produto ilícito em pó, guardadas no bolso de sua bermuda, foi surpreendido quando, hirto e estático na via pública, possivelmente aguardava contato com usuários para vender-lhes porções do entorpecente.

É da exordial que, em seguida, mediante diligência policial ulterior logo realizada pelos agentes policiais nas cercanias, engendrada mediante indicações fornecidas pelo próprio réu, verificou-se que, em terreno baldio localizado no segundo logradouro citado, qual seja, na Avenida Vila Velha, ele ali ocultava na encorpada vegetação existente outras trinta (30) embalagens da cocaína em pó e dezesseis (16) unidades da mesma substância ilícita no formato de crack.

Segundo a denúncia, verte do incluso caderno investigatório que os réus LEANDRO e NICOLAS, vulgo "Nicão", juntamente com terceiro não identificado somente conhecido pela alcunha "Radical", associaram-se de forma estável e duradoura, eis que anteriormente concertaram as suas vontades para a consecução do propósito criminoso que os animava, agindo assim em concurso associativo e comungando do mesmo desiderato ilegal, para o fim de praticarem o comércio ilícito de drogas.

Narra a inicial que, adrede mancomunados e concertados, unindo suas vontades para a concreção do narcotráfico, encarregava-se o réu LEANDRO da venda das drogas, as quais lhe eram periodicamente entregues (a exemplo das apreendidas nestes autos) pelo réu NICOLAS, gerente de ponto de venda do produto ilícito conhecido no jargão popular como biqueira, a qual era comandada pelo desconhecido "Radical".

A prisão em flagrante do réu Leandro foi convertida em prisão preventiva (fls. 48/52 e 77/78).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 93/95), o réu Leandro foi pessoalmente notificado (fls. 121) e apresentou defesa preliminar através da Defensoria Pública (fls. 126).

O réu Nicolas não foi encontrado para ser notificado (fls. 122), e procedeu-se sua citação por edital (fls. 138/139, 156/157, 169/171). Não comparecendo espontaneamente, e não constituindo advogado para lhe patrocinar, suspendeu-se o processo e o curso da prescrição, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, antecipando-se as provas com relação a ele (fls. 138/139).

A denúncia foi recebida em 16 de maio de 2022 (fls. 139) e o réu Leandro foi devidamente citado (fls. 180).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu Leandro foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação, pois não foram colhidas provas suficientes quanto à prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Prova segura quanto ao crime de tráfico de drogas. Primário, confesso, fazendo jus ao privilégio. Regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incineração da droga. Recurso em liberdade.

A Defesa manifestou-se nos mesmos termos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é parcialmente procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu Leandro cometeu o delito de tráfico de drogas que lhe imputa a inicial acusatória, todavia, com relação ao crime de associação para o tráfico, de rigor sua absolvição.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/28), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu Leandro,

que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 07), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18), pela informação acerca dos vulgos "Nicão" e "Radical" (fls. 85), pelo comprovante de depósito judicial da quantia apreendida (fls. 101), pelo exame químico-toxicológico, que constatou a presença da substância cocaína nos materiais apreendidos (fls. 184/186), e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O réu Leandro, ouvido em solo policial (fls. 04), declarou que "cientificado de seus direitos aduz que não tem advogado e que sua genitora foi comunicada de sua prisão. Confessa a prática de tráfico de drogas. Afirma que trazia consigo certa quantidade de drogas e que guardava o restante em um terreno baldio e indicou aos policiais onde os guardava. Informando que praticou o tráfico e ficou um tempo sem fazer 'o corre' a tempo e retornou ontem pois tinha uma dívida. Informa que o gerente da biqueira é de seu cunhado Nicolas e que foi terceiro (dados ignorados) quem deixou a droga com o interrogando. Informa que vendia cada pino a R\$ 10,00 (dez reais) e que praticava tal conduta para pagar uma dívida de droga. Foi cientificado que o tráfico é inafiançável. Posteriormente, o interrogando quis novamente informar dados referentes ao feito apurado. Alega que foi abordado por volta das 15:00 horas pela polícia militar e consigo foi encontrado pó e 'dura', sendo que comenta que durante a abordagem chegou a consumir um pino de cocaína. Os policiais indagaram o interrogando solicitando onde teria mais droga e arma, sendo que informou os agentes o terreno baldio onde estava as drogas. Relata que tomou tapas na face para falar onde teria mais drogas e que foi ameaçado de morte pelos policiais. Comenta que a droga encontrada no terreno é de propriedade de Nicolas, vulgo Nicão. Alega que durante a abordagem o Nicolas passou pela via, foi abordado pelos milicianos e após conversa com os policiais foi liberado. Informa que o local possui câmara do COI. Alega que ouviu Nicolas relatar aos milicianos que iria dar uma arma aos policiais. Ao final comenta que caso tivesse entregue um revólver aos policiais seria liberado da ocorrência. Ademais confessa que estava no local praticando tráfico de drogas por ter dívidas de drogas com o dono da boca de alcunha Radical (gordo de barba), sendo que o gerente da boca é seu cunhado Nicão" (sic).

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu Leandro disse que tem 19 anos, já foi pra a delegacia por causa de um furto, com uns 14 anos. Fumava só maconha. Trabalhava com seu pai, mas sofreu um acidente, perdeu a movimentação do seu braço. Foi vender a droga mesmo, tem uma filha recém nascida, está arrependido. Sua esposa não trabalha. Até colaborou com os policiais. Bateram nele sim, por isso levou-os onde estava o resto da droga. Tinha um pouco de droga em seu bolso, deram tapa na cara, por isso falou onde tinha mais droga. Pode morrer ou ser preso vendendo droga. A droga que estava escondida era dele mesmo. Soube que Nicolas era gerente da biqueira no dia em que foi preso. Foi melhor ter ido preso, para aprender. Não trabalhava para Nicolas. "Radical" era o dono da biqueira, mas nunca viu ele, ouviu o rapaz falar com ele no celular. Não estava devendo na biqueira. João, que está na Fundação Casa, fez a proposta para vender a droga para ele. Foi preso uma semana depois.

O réu Nicolas não foi ouvido na primeira fase da persecução penal.

Não foi ouvido, pois está em local incerto e não sabido.

As testemunhas Marcos e José, Policiais Militares, ouvidos na delegacia (fls. 02/03), relataram que "durante patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos (rua Lourenço da Veiga, 70, Ipanema, Taubaté/SP), avistaram um indivíduo em atitude suspeita, o que ensejou a abordagem. Durante revista pessoal, localizaram no bolso da bermuda do indiciado, 8 (oito) porções de substância pulverizada branca semelhante a cocaína, 10 (dez) porções de substância petrificada semelhante ao crack, bem como 1 (um) telefone celular e a quantia de R\$ 39,00 (trinta e nove reais). Ao ser indagado, o indiciado LEANDRO DE SOUZA LIMA confessou atuar na mercancia de drogas naquele local e indicou um local onde haveria mais entorpecente. Em vista disso, rumaram a avenida Vila Velha, 116, Ipanema, Taubaté/SP, ocasião em que solicitaram apoio do BAEP CANIL para vistoriar o local,

haja vista tratar-se de matagal, sendo que após vistoria no terreno baldio indicado por LEANDRO, encontraram outras 30 (trinta) porções de substância branca pulverizada semelhante a cocaína e 16 (dezesseis) porções de substância petrificada semelhante ao crack. Em vista disso, conduziram o indiciado e apresentaram os fatos a autoridade policial para as providências de Polícia Judiciária." (sic).

Em juízo o policial militar Marcos disse que estavam em patrulhamento, já tinham conhecimento do tráfico de entorpecente na via. Ao ver a equipe Leandro tentou sair do local andando. Fizeram a abordagem. Ele trazia drogas consigo. Perto de onde ele estava acharam alguns pinos de cocaína e trouxas de crack. O dinheiro estava escondido próximo dali. Ele disse que fazia o tráfico no local. Apontou outro endereço, terreno baldio, onde teria mais droga escondida. Ele apontou exatamente onde estava a droga, encontraram. Disse que tinha mais droga ali, chamaram o canil, mas não localizaram mais nada. Ele mencionou que outros indivíduos faziam o tráfico de drogas, mas não estavam no local. Acha que "Nicão", cunhado dele, e "Radical". Naquele dia "Nicão" não estava ali. Não conhecia Leandro. Ele tinha alguma droga consigo. Na esperança de ser solto, ele contou onde tinha mais drogas. Havia um bar, moradores, pelo local. Conversando com o réu não havia ninguém.

Em juízo o policial militar José Washington disse que estavam em patrulhamento pelo bairro, local conhecido pelo tráfico de drogas, abordaram o réu, com quem encontraram entorpecentes. Ele falou que fazia o tráfico de drogas ali e que guardava drogas em outro local, um terreno. Não viram ato de comércio. Ele tinha pedras de crack e pinos de cocaína. Não conhecia o réu. "Nicão" é um traficante conhecido do meio policial. O réu mencionou ser cunhado de Nicão, que ele faria o tráfico de drogas ali, mas não necessariamente com ele. Não se lembra o que foi dito sobre "Radical". Parece que era quem levava a droga para ele vender, escondia no terreno.

Não restam dúvidas de que o réu cometeu os delitos que lhe imputa a inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando se depararam com o réu Leandro em atitude suspeita e optaram por abordá-lo. Em revista pessoal, os agentes encontraram, no bolso da bermuda que ele vestia, 8 (oito) porções de cocaína, 10 (dez) porções de crack, um telefone celular e R\$ 39,00 (trinta e nove reais).

Informalmente questionado pelos policiais, o réu Leandro confessou a prática da mercancia ilícita de entorpecentes e indicou um local onde tinha mais entorpecentes.

Destarte, os policiais foram ao local indicado, onde lograram êxito em localizar 30 (trinta) porções de cocaína e 16 (dezesseis) porções de crack.

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu Leandro reiterou sua confissão e alegou que retornou à prática do tráfico de drogas no dia anterior aos fatos, em razão de uma dívida que tinha com o dono do ponto de drogas.

Em juízo, confessou a prática do tráfico de drogas. Contou que ficou sabendo no dia que foi preso que o corréu é traficante. Negou que a propriedade das drogas era de Nicolas, afirmando que toda a droga era de sua propriedade.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112).

Os policiais foram firmes e coesos em suas declarações, narrando toda dinâmica de suas atuações, descrevendo com clareza toda a abordagem do réu Leandro.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa.

Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

O réu confirmou a narrativa policial, admitindo que fazia o tráfico de drogas e que mostrou aos policiais onde escondia o restante da droga destinada à venda.

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo, e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que o réu Leandro trazia consigo e tinha em depósito os entorpecentes, sendo desnecessário ter sido flagrado em ato de venda.

Nesse sentido: Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câmara. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

E ainda: O crime de tráfico não se consuma apenas com o fato do agente trazer consigo o entorpecente, pois o tipo penal traz diversas figuras típicas, dentre as quais o depósito da droga, o que fica caracterizado na hipótese de o réu ter enterrado na sua residência a substância em local cercado por grades e, portanto, de difícil acesso a estranhos, não restando demonstrada a alegação de que a droga não era sua, ou que não tinha conhecimento da mesma (TJRS, Ap. 699.232.609, 3ª Câmara, j. 30-9-1999, rel. Des. Saulo Brum Leal, RT 777/688).

As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

A materialidade está bem demonstrada, pois tanto o laudo de constatação provisória (fls. 20/26), quanto o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 184/186), confirmaram a ilicitude das substâncias apreendidas, identificadas como sendo cocaína.

Sobreleva notar que a quantidade de droga apreendida (18,7g de cocaína em sua forma pura - pó branco de granulometria fina e 6,1g de cocaína em sua forma petrificada - crack), a forma de acondicionamento (a cocaína distribuída em 38 invólucros e o crack disposto em 26 pedras), as circunstâncias em que ocorreram os fatos (policiais que estavam em patrulhamento de rotina quando optaram por abordar o réu Leandro, oportunidade em que encontraram com ele parte das drogas apreendidas e ele confessou a prática do tráfico, bem como indicou um local onde tinha mais drogas) e a quantia em dinheiro apreendida (R\$ 39,00), evidenciam de forma clara o intuito da mercancia.

É de se observar, ainda, que o réu não possui antecedentes desabonadores, levando a crer que o réu não se dedica a atividades criminosas com habitualidade, tampouco que integra organização criminosa. Desta forma, preenchidos os requisitos legais, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena, com fundamento no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

Portanto, de rigor a condenação pelo crime tipificado no artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, nota-se que sua ocorrência não ficou comprovada.

Como se sabe, a associação para o tráfico é um delito em que duas ou mais pessoas se unem com a finalidade de praticar os crimes tipificados nos artigos 33, caput e §1º, e 34, todos da Lei n. 11.343/06.

Este delito reclama estabilidade e permanência entre as pessoas, do contrário, não passaria de concurso de pessoas.

De acordo com os ensinamentos do professor Renato Brasileiro de Lima, "a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão 'reiteradamente ou não', a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas

sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)" e que "uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei 11.343/2006". (Legislação Criminal Especial Comentada, 6ª edição, editora JusPodivm, p. 1048/1049).

Este, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO

ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. (...) (STF, HC 124164, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, j. em 11/11/2014, pub. em 24/11/2014 – destaquei).

Os juristas Renato Brasileiro de Lima e Guilherme de Souza Nucci ensinam que a associação para o tráfico de drogas estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Portanto, configurar-se-á o delito ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e permanência da associação (Legislação Criminal Especial Comentada, 6ª edição, editora JusPodivm, p. 1049).

É a conduta de se associar que necessita de estabilidade e permanência, podendo existir o delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 se os agentes se unirem diversas vezes com o intuito de, por exemplo, transportar drogas para outro local, ainda que o transporte ocorra apenas uma vez.

Portanto, forçoso concluir que o crime de artigo 35 da Lei 11.343/2006 se trata de uma associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, com o fim de praticar por uma única vez, ou várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34, da Lei de Drogas.

De fato, o réu contou que as drogas estavam sob sua responsabilidade e que o dono do ponto de vendas era "Radical". Disse que tomou conhecimento naquele dia que seu cunhado era traficante.

Há inclusive a declaração do policial José Washington dizendo que o réu contou que era cunhado de Nicão, mas que não praticava as condutas conluiado a ele.

Não há nos autos prova de permanência ou estabilidade das condutas do réu com o réu Nicolas, tampouco com outra pessoa não identificada, até porque contou ainda que estava no local há uma semana, não sendo suficiente para a demonstração dos requisitos legais.

Inclusive este é o teor do pedido final da acusação.

Impõe-se, portanto, diante da fragilidade probatória, a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Como é cediço, uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, cabendo lembrar memorável pronunciamento de MALATESTA, segundo qual "o direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo; por isso, absolvendo um caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do acusado e não oprime o da sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranquilidade social, mais do que a teria abalado o crime particular que se pretendesse punir; porquanto todos se sentiriam na possibilidade de serem, por sua vez, vítimas de um erro judiciário. Lançai na consciência social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora daquela mesma tranquilidade para cujo restabelecimento foi constituída; não será a defensora do direito, e sim a força imane que pode, por sua vez, esmagar o direito indêbil" (in "Lógica das Provas", Ed. Saraiva, págs. 14/15).

Sendo assim, de rigor sua absolvição com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06.

Deve o réu Leandro, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado Leandro não ostenta antecedentes desabonadores (fls. 29 e 149/150). Deve-se, ainda, ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de entorpecentes, a personalidade e a conduta social dos agentes. Assim, há de se considerar a natureza deletéria de uma das drogas apreendidas, cocaína em forma de pedra crack, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas extremamente violentas nos casos de abstinência e que acaba empurrando os usuários a outros crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais e mais drogas, circunstâncias que aumentam a culpabilidade do agente e as consequências do delito. Ainda levo em consideração a variedade de droga apreendida (cocaína e crack), o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, indicando que o réu está mais inserido no mundo do crime, lidando com diversos tipos de drogas e alcançando um número maior de usuários, evidenciando sua maior dedicação em comercializar entorpecentes, em detrimento da saúde de terceiros. Assim, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, para que fique em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A exasperação da pena base mostra-se necessária em razão da natureza da droga traficada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 2. Trata-se o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de norma de direito material de observância obrigatória quando da fixação da pena nos delitos por ela regulados por imperativo constitucional, eis que beneficia o agente dada a possibilidade de redução da reprimenda. 3. Faz jus à diminuição da pena o paciente que preenche todos os seus requisitos, não sendo motivação idônea para se afastar a incidência da minorante a menção no sentido de ser o paciente detentor de maus antecedentes levando-se em conta condenação ainda não transitada em julgado. 4. Habeas corpus denegado, e concedida a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena do paciente na ação penal de que aqui se cuida a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa" (STJ, HC 152.285/SP, Ministro Relator Haroldo Rodrigues, j. em 23/02/2010 - destaquei).

O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A reprimenda mostrou-se adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 126 tráfico) e pela potencialidade lesiva da droga, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 125 roubo circunstanciado), alcançando a pena final de 07 anos de reclusão; não aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante da reincidência. Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como estabelecida" (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0004327-68.2012.8.26.0292. Relator Des. Marco de Lorenzi. J. em 04/07/2013 - destaquei).

Ausente agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea minoro a reprimenda impostas ao réu em 1/6, para que passe a ser 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo impossível a redução da pena nesta fase aquém deste patamar mínimo.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desposado na Súmula n. 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução

da pena abaixo do mínimo legal".

Ausentes causas de aumento e, em razão do que preceitua o § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, por ser o réu é primário, de bons antecedentes, inexistindo notícia de que integre organização criminosa ou prova de habitualidade criminosa, reduzo a reprimenda em 2/3, para que fique em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A mingua doutras causas modificadoras das reprimendas, torno-as definitivas.

Considerando a decisão proferida no HC n.º 596.603, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 08 de setembro de 2020, bem como à vista dos elementos dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (pena não superior a quatro anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais que não são desfavoráveis) do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem o réu direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal. Inviável a suspensão condicional da pena, porquanto a pena restritiva de direitos é ao réu mais benéfica.

Em caso de revogação do benefício, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c" e §3º, do Código Penal, pois deve-se considerar a variedade de drogas traficadas e a natureza deletéria do crack.

Ainda que se tenha que levar em consideração a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para a fixação do regime, neste caso, não haverá qualquer modificação fática, porquanto o réu ficou preso por três meses, não sendo suficiente para modificar o regime inicial para o cumprimento de sua pena.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR LEANDRO DE SOUZA LIMA, filho de José Rubens de Souza Lima e Maria Aparecida de Souza Dias, RG n.º 39.043.199, nascido aos 16 de novembro de 2002, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 33, caput, Lei n.º 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação de crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal.

Ante a pena aplicada, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Condene o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e no artigo 62 da Lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder do réu (depósito judicial às fls. 101), porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado

em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Desmembrem-se os autos em relação ao acusado NICOLAS HENRIQUE RODRIGUES SALGADO, oficiando-se a autoridade policial para que diligencie para encontrá-lo. Diante da economia processual, determinou-se a colheita antecipada de provas (fls. 138/139). Atente-se a Serventia para que, quando do cumprimento do desmembramento, copie as mídias da audiência de instrução para o processo desmembrado.

Lance-se, com o trânsito em julgado, o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento das reprimendas.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA